

1525218-34.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1525218-34.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525218-34.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2201179/2022 - 01º D.P. SE, 26338572 - 01º D.P. SE, 2201179 - 01º D.P. SE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GORA NDIAYE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

GORA NDIAYE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, §§ 1º e 2º, por duas vezes, na forma do artigo 69, caput, ambos do Código Penal porque entre os dias 21 de maio e 25 de julho de 2022, e neste dia, por volta de 12h13min, na Rua Irmã Simpliciana, altura do nº 23, nesta cidade e Comarca de São Paulo/SP, adquiriu/recebeu e expunha à venda, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, 01 (um) aparelho celular Samsung, IMEI 355253113180844, que devia saber ser produto de crime anterior em prejuízo da vítima Leonardo Fernandes de Moraes Alves.

Consta, ainda, que no dia 25 de julho de 2022, por volta de 12h13min, na Rua Irmã Simpliciana, altura do nº 23, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, o réu adquiriu/recebeu e expunha à venda, em proveito próprio, no exercício de atividade

comercial, um aparelho celular Motorola, que devia saber ser produto de ilícito, em prejuízo da vítima Daniela de Almeida Yamashita.

A denúncia foi recebida em 08 de agosto de 2022 (fls. 85/87). O réu foi pessoalmente citado e ofertou defesa preliminar (fls. 132/133).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas em comum pelas partes. Em seguida o réu foi interrogado. Pelas partes não foram requeridas diligências.

A acusação requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, com reconhecimento da continuidade delitiva.

A defesa postulou a absolvição pela ausência de prova quanto à receptação do aparelho que não estava em poder do réu, bem como afastamento da figura qualificada, com incidência da figura simples. Postulou, ainda, fixação da pena no mínimo legal, incidência da atenuante da confissão, regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é totalmente procedente.

A vítima Leonardo declarou que no dia dos fatos estava na frente de sua casa, com seu celular em mãos, quando um indivíduo passou em uma bicicleta e subtraiu o aparelho. Só soube da localização do aparelho quando da intimação para a presente audiência. Pretende reaver o aparelho.

Os policiais civis narraram que existe uma operação permanente no distrito policial em que trabalham para combate ao tráfico e ao comércio de mercadoria ilícitas (chamada feita do rolo) no local dos fatos, conhecido local pela prática de tais delitos. Estavam realizando observação velada, quando viram o réu passando um celular para outro homem, posteriormente identificado como a testemunha Eliseu. Por isso, decidiram proceder à abordagem. Com Eliseu foi encontrado apenas o celular que viram o réu passando para ele há pouco. Efetuada consulta com relação a tal aparelho, nada constou como ilícito. Com o réu foi encontrado outro aparelho celular, o qual constava como de origem ilícita. Eliseu disse que estava ali para negociar a compra do celular com o réu. Para o policial Fabio o réu nada disse. Para o policial Luiz Carlos o réu disse que o aparelho que estava com Eliseu não era seu. Em revista o réu, mesmo a feita de forma mais minuciosa, nada mais foi encontrado naquele dia. No dia seguinte, foram avisados pelos policiais do 77º DP que haviam encontrado R\$ 1.750,00 no calçado do réu, que afirmou que o dinheiro era de um benefício social que recebia. O policial Fabio relatou que mais tarde, já no distrito policial, lograram visualizar um e-mail na tela do aparelho que estava em poder de Eliseu e, realizada busca, encontraram um boletim de ocorrência com aquele e-mail e fizeram contato com uma pessoa que se identificou como proprietária do celular. Ela compareceu no distrito policial, relatou que havia sido vítima de furto naquele mesmo dia por volta das 10 horas na região central da cidade e que não havia tido tempo de efetuar o registro da ocorrência. Ela desbloqueou o aparelho e apresentou a caixa do equipamento, bem como documentos de aquisição, motivo pelo qual o aparelho foi-lhe entregue. Reconheceu a pessoa do documento de fls. 37 como sendo a proprietária do aparelho. Não conheciam o réu anteriormente. O réu foi abordado por volta das 12 horas.

O réu, em seu interrogatório, disse que estava em poder apenas do aparelho Samsung, o qual afirma que comprou de um indivíduo que conhecia apenas de vista pelo valor de R\$ 700. Nega que estivesse com o aparelho Motorola. Não conhecia os policiais. Estava no local com um amigo, que o ajudaria a regularizar sua documentação no país.

A pretensão punitiva estatal deve prosperar. A materialidade delitiva com relação ao celular Samsung (vítima L.) está comprovada pelo boletim de ocorrência do crime antecedente (fls. 39/40) e pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12. Com relação ao celular Motorola, a materialidade delitiva está comprovada pelo depoimento do policial Fabio, que confirmou que a vítima (reconhecida na foto de fls. 37) compareceu no distrito policial após ter sido identificada por meio de um e-mail que apareceu na tela do celular. Ela relatou ter tido seu celular furtado na data dos fatos, por volta das 10h da manhã, na região central, não tendo elaborado boletim de ocorrência por não ter dado tempo. Não há qualquer necessidade de

juntada do respectivo boletim de ocorrência, uma vez que a lei assim não exige. A apreensão do celular fora da esfera de disponibilidade da vítima (fls. 11/12) é o maior demonstrativo de que foi subtraída da posse de seu autêntico proprietário anteriormente.

A autoria delitiva decorre dos depoimentos colhidos na presente data.

A vítima L. confirmou ter tido seu celular subtraído no mês de maio.

Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si e em consonância com o depoimento da testemunha E., ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)”

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Existe perfeita harmonia e coerência entre a narrativa fática e toda prova produzida, de forma a não deixar dúvidas de que o acusado praticou o crime de receptação qualificada, pois ele foi flagrado pelos policiais no momento em que negociava um dos celulares com a testemunha E., ainda que na via pública, na modalidade de comércio irregular, o que foi confirmado pela testemunha E. na fase policial. Os policiais ainda relataram que o local é conhecido pela alta incidência da prática de tal tipo de crime, sendo conhecido como “feira do rolo”. Por tais elementos, configura-se a certeza de que o réu agiu, no mínimo, com dolo eventual, assumindo o risco de produzir o resultado que é a prática da receptação. Além disso, é perfeitamente possível extrair o dolo direto do réu através das circunstâncias e da conduta que ele teve ao adquirir/receber os celulares e passar a negociar a venda de referidos aparelhos a terceiros em plena rua.

Induvidoso, portanto, que os aparelhos celulares estavam em poder do réu no momento da abordagem, de forma que a questão posta em Juízo cinge-se à discussão sobre a ciência prévia do réu quanto à origem ilícita.

O E. STJ pacificou o entendimento de que, em sendo o bem espúrio encontrado com o réu, compete a ele demonstrar de forma cabal nos autos a aquisição de forma lícita, trazendo ao Juízo elementos que afastem o seu dolo. Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO RÉU. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.(...).” (grifei) (STJ, HC 398211 / SP, rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 27/06/2017).

No mesmo sentido: STJ, HC 396118 / SC, rel. Ministro FELIX FISCHER e STJ, HC 398211 / SP, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS.

No presente caso, verifica-se que réu não logrou êxito em trazer ao conhecimento deste Juízo qualquer prova que tenha o condão de demonstrar a aquisição lícita dos celulares que foram encontrados em sua posse. Frise-se, ainda, que através de uma rápida consulta à internet, por meio de acesso a endereços eletrônicos diversos, como <https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/celular-legal> ou <https://www.consultaaparelhoimpedido.com.br>, que podem ser localizados por meio de simples busca em sites de consulta (como Google, por exemplo), é possível a qualquer pessoa verificar a existência de alguma restrição em relação a qualquer aparelho celular, de forma a proceder à uma aquisição segura. No presente caso, não há nenhuma comprovação de que o réu tenha efetuado qualquer pesquisa mínima que pudesse indicar que ele tentou verificar a procedência do celular, de modo a afastar seu dolo quanto à aquisição de celular de procedência ilícita.

Daí porque se torna insustentável o quanto aduzido pela defesa no sentido de que o acusado não tinha nenhum conhecimento acerca da origem espúria dos aparelhos celulares vez que todos os elementos circunstanciais acima indicados deixam claro o oposto, inexistindo qualquer prova que sustente, ainda que minimamente, sua versão. Pelos mesmos motivos, inviável a desclassificação da conduta do réu como pretendido pela defesa.

Forçoso, ainda, reconhecer-se que duas foram as receptações praticadas pelo réu em concurso formal, porquanto se apoderou dos bens de duas vítimas distintas e individualizáveis, já que se apoderou dos celulares das vítimas L. e D e estava em poder deles no mesmo contexto fático, visando à venda.

Confira-se:

“Concurso formal: ação única, ainda que desdobrada em atos diversos, da qual resultou a lesão patrimonial de vítimas diferentes: jurisprudência do STF firmada para elidir a tese do crime único, mas que afasta também a existência em tais hipóteses de crime continuado, que reclama pluralidade de ações: consequente descabimento da duplicação da pena base, fundada no art. 71, parág. Único, da qual, em se tratando de concurso formal, só poderia resultar de autonomia de desígnios, (CP, art. 70, in fine), da qual não se cogitou na espécie” (JSTF 171/323).

(...). A subtração de patrimônios de vítimas diversas numa mesma ação caracteriza concurso formal próprio, nos termos do artigo 70, caput, 1ª parte, do Código Penal. (...). (Acórdão n.1110943, 20171510061039APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/07/2018, Publicado no DJE: 30/07/2018. Pág.: 97/114)”.

Por fim, não é possível considerar-se a versão do réu como confissão. Ora, ele afirma que estava na posse de apenas um dos aparelhos celulares, que afirma ter comprado para seu próprio uso, negando que tivesse a intenção de o vender, afirmando que estava ali para encontrar um amigo. Não há como se considerar como confissão sua versão pelo simples fato de reconhecer a posse de um dos aparelhos. Assim, a pretensão punitiva merece prosperar, impondo-se a condenação do acusado nos termos acima expostos, restando apenas a DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase da dosimetria, não há circunstâncias judiciais que indiquem a necessidade de majoração das penas, que são fixadas no mínimo legal de 03 (três)

anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para cada uma das receptações. Ausentes agravantes e atenuantes a serem consideradas. Por fim, em razão do concurso formal entre as duas receptações acima reconhecidas, as penas devem ser elevadas na fração de 1/6, ficando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, sendo definitivamente fixada neste patamar posto que ausentes causas de diminuição. As condições do réu são modestas de modo que fixo cada dia-multa em seu valor mínimo legal.

Em observância aos critérios do artigo 33 do Código Penal, fixo o regime inicial de cumprimento da pena corporal imposta o regime aberto, diante da quantidade de pena ora aplicada e de sua primariedade técnica.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu GORA NDIAYE, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 180, §§ 1º e 2º, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Estando presentes os requisitos dos artigos 44 e 46 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período de condenação em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções, bem como por pena de multa no valor correspondente a 01 (um) salário(s) mínimo(s), também em favor de entidade a ser indicada pela Vara das Execuções.

Tendo em vista o regime para início de cumprimento de pena ora fixado e a substituição por restritivas de direito acima procedida, defiro ao réu o direito ao recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

Custas na forma do artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/03.

Com relação ao valor apreendido em poder do réu (R\$ 1750,00 - fls. 51), defiro-lhe prazo de 90 dias (artigo 123 do CPP) para comprovação de sua licitude a fim de que seja determinada a liberação da quantia, sob pena de perdimento em favor da União. Considerando tratar-se de pessoa estrangeira, comunique-se a prolação da presente sentença à missão diplomática de seu país de origem ou, na falta, ao Ministério das Relações Exteriores, e ao Ministério da Justiça

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de setembro de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA